

刑法
No160

R3-5

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】及び各【見解】に関する後記1から5までの各【記述】を検討した場合、誤っているものはどれか。なお、共同正犯に関する刑法第60条は、結果的加重犯にも適用されることを前提とする。

【事例】

甲乙両名は、2人でVに向けて石を投げることにし、それぞれVに石を投げた。その際、甲には、傷害の故意しかなかったのに対し、乙には、未必的な殺意があった。両名が投げた石のうち、甲の投げた石がVの頭部に当たり、Vが死亡するに至った。

【見解】

A説：共同正犯とは、数人が共同して特定の犯罪を行うことであり、構成要件の間に重なり合いがあれば、そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しか有しない者には、軽い犯罪の刑を科す。

B説：共同正犯とは、数人が共同して特定の犯罪を行うことであり、構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認め、重い犯罪の故意を有する者には、共同正犯とは別に、その故意に応じた単独犯の成立を認める。

C説：共同正犯とは、数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり、特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろん、単なる行為を共同して各自の意図する犯罪を実現する場合も、それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。

【記述】

1. A説からは、甲と乙に殺人罪の共同正犯が成立するとの結論が導かれる。
2. A説に対しては、罪名と科刑が分離し、妥当でないとの批判がある。
3. B説に対しては、重い犯罪の故意を有する乙について、重い犯罪の単独犯として構成した場合には、自らの行為と死亡結果の因果性を欠くことから、殺人既遂罪の成立を認めることが困難となるとの指摘がある。
4. B説とC説とで、甲に成立する罪名は異ならない。
5. C説からは、甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立するにとどまるとの結論が導かれる。

No160

R3-5

結果的加重犯の共同正犯

正解

5

正答率

84%

1 正しい

A説（かたい部分的犯罪共同説）によると、【事例】の甲と乙には殺人罪（199条）と傷害致死罪（205条）のうち、重い殺人罪の共同正犯が成立するが、傷害の故意しかなかった甲には傷害致死罪の刑を科することになる。したがって、本記述は正しい。

2 正しい

A説によると、甲には殺人罪の共同正犯が成立するが、傷害致死罪の刑が科せられる（肢1解説参照）。これに対しては、罪名と科刑が分離し、妥当でないとの批判がある。したがって、本記述は正しい。

3 正しい

B説（やわらかい部分的犯罪共同説）によると、【事例】の甲と乙には、殺人罪と傷害致死罪の重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立し、重い殺人罪の故意を有する乙には、別途殺人罪の単独正犯が成立することになる。これに対しては、（【事例】のように甲の投げた石がVの頭部に当たり、Vを死亡させた場合）乙の行為と死亡結果の因果性を欠くことから、乙に殺人既遂罪の成立を認めることが困難となるとの指摘がある。したがって、本記述は正しい。

4 正しい

B説によると、甲には傷害致死罪の共同正犯が成立する（肢3解説参照）。また、C説（行為共同説）によると、甲には傷害致死罪の共同正犯が成立し、乙には殺人罪の共同正犯が成立することになる。よって、B説とC説とでは、いずれも甲に傷害致死罪が成立するので、成立する罪名は異なる。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

C説によると、甲には傷害致死罪の共同正犯が成立し、乙には殺人罪の共同正犯が成立する（肢4解説参照）。したがって、本記述は、C説からは、甲と乙に傷害致死罪の共同正犯が成立するにとどまるとの結論が導かれるとしている点で、誤っている。